

N. R.G. 2856/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Carlo Maddaloni	Presidente rel.
dr. Giovanna Ferrero	Consigliere
dr. Antonio Corte	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **2856/2020** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1

-

Parte_2

(C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliata in VIA FONTANA, 11 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. VERDI MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

CP_1 (C.F. *P.IVA_2*), elettivamente domiciliata in VIA NAPO TORRIANI, 33 22100 COMO presso lo studio dell'avv. PILLOSIO VALENTINA, che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATA

avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)

sulle seguenti conclusioni.

Per *Controparte_2*

Piaccia all' Ill.mo Collegio adito, previa, se del caso, ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, in integrale riforma della predetta impugnata sentenza n. 773/2020, emessa, all'esito di trattazione scritta ex art. 83 lett. H della Legge 24 aprile 2020, n. 27, il 7 ottobre 2020, notificata il successivo 3 novembre, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Como, dott. Andrea Canepa, *sub* R.G. n. 1508/2017, accogliere le seguenti domande:

- 1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1439, comma 1 e 2, c.c., e/o, comunque, l'illiceità, ex art. 1440 c.c., del contratto di spedizione intercorso tra *Controparte_2* e *Controparte_1* per tutte le ragioni dettagliatamente indicate nella parte motivata del presente atto;
- 2) per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da *Controparte_2* nei confronti della società opposta, *Controparte_1* per essere la pretesa azionata in via monitoria del tutto infondata, illegittima, ingiusta, per tutte le ragioni dettagliatamente indicate nella narrativa che precede;

In via riconvenzionale,

- 3) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di *Controparte_2* di ripetere, nei confronti di *Controparte_1* le somme indebitamente corrisposte, in favore

di quest'ultima, a titolo di rimborso di spese di sosta non effettivamente sostenute, nella sopra indicata misura di €. 346.660,60, ovvero, nella diversa, maggiore o minore, misura, che risulterà effettivamente dovuta ad istruttoria ultimata;

4) per l'effetto e in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare *Controparte_1* al risarcimento di tutti i danni patiti da *Controparte_2* in conseguenza della condotta *contra legem* dalla stessa tenuta, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale, nella misura che risulterà accertata e/o che sarà, comunque, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, all'esito del presente giudizio;

In via subordinata,

5) nella denegata, e non creduta, ipotesi, in cui le superiori domande ed eccezioni, non dovessero trovare accoglimento, accertare e dichiarare il diritto di *CP_2* [...] di opporre in compensazione, nei confronti della somma azionata da *Controparte_1* in sede monitoria, il controcredito vantato nei confronti di quest'ultima a titolo di somme che dovessero risultare corrisposte indebitamente, a titolo di soste non sostenute, e/o a qualsiasi altro titolo, sino a concorrenza dei relativi crediti;

Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria:

Si chiede disporsi CTU tecnica d'ufficio volta a quantificare sulla base di tutta la documentazione agli atti di causa, l'ammontare delle somme indebitamente riscosse da *Controparte_1* a titolo di spese di sosta non dovute, fatte oggetto della domanda riconvenzionale di questa esponente.

Per *CP_1*

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza,

eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:

NEL MERITO, - Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da *CP_2* , confermando la sentenza n.773/2020 pubblicata il 7.10.2020 resa dal Tribunale di Como in data 7.10.2020 , oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute; - respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore-appellante contro *Controparte_1* per i motivi esposti in narrativa .

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Como, con la sentenza n.773\2020, pubblicata il 7 ottobre 2020, pronunciando sull'opposizione proposta da *Controparte_2* (d'ora in avanti *CP_2* al decreto ingiuntivo ottenuto da *Controparte_1* per l'importo di euro 83.980,69 per corrispettivi di servizi di spedizione, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la parte opponente a corrispondere alla parte opposta la somma di euro 76.232,69 oltre interessi, respingendo tutte le altre domande ed eccezioni delle parti, compensando per il 50% le spese di giudizio, poste nella restante parte a carico di *CP_2*

Le pregresse vicende processuali possono riassumersi come di seguito.

La *CP_1* otteneva un decreto ingiuntivo, per l'importo di euro 83.980,69, per servizi effettuati in favore della *CP_2* in esecuzione di un contratto di spedizione concluso in nome proprio e per conto della ingiunta, per i quali erano state emesse fatture non onorate dalla debitrice.

La *CP_2* si opponeva al suddetto decreto, assumendo che, in seguito ad accertamenti compiuti, aveva appurato che nel periodo dal 2010 al 2016, la *CP_1* aveva preteso ed ottenuto dalla medesima compensi maggiori di circa il 40-50% rispetto a quelli usualmente praticati dagli operatori del settore, ed aveva inoltre addebitato rilevanti costi a titolo di sosta della merce, non dovuti, in quanto non effettivamente sostenuti.

Gli ingiusti vantaggi economici ottenuti da *CP_1* erano stati conseguiti a causa della illecita condotta posta in essere da *Controparte_3*, il quale, nella sua qualità di direttore operativo della società opponente, approfittando della enorme autonomia gestionale, operativa e decisoria conseguita dal medesimo all'interno della *CP_2* aveva illegittimamente acconsentito a che *CP_1* rendesse i detti servizi di spedizione a prezzi notevolmente superiori a quelli di mercato ed esponesse nelle varie fatturazioni indebiti costi per la sosta delle merci trasportate.

L'opponente, dopo avere dato atto di avere presentato denuncia querela innanzi alla Procura della repubblica di Lecco per i detti fatti, assumeva anzitutto come nel ricorso fossero state indebitamente computate, per due volte, due identiche fatture, sì che, in ogni caso, la somma dovuta non poteva essere superiore a complessivi euro 76.231,69.

La *CP_2* assumeva di nulla dovere alla *CP_1*, per avere quest'ultima approfittato della complicità del sig. *CP_3*, per essere preferita ad altri operatori più convenienti e per avere conseguito rimborsi per spese di sosta non dovuti.

Secondo l'opponente il contratto di spedizione stipulato tra le parti, dal quale originavano le pretese creditorie della CP_1 , doveva essere annullato, ex art. 1439 c.c., per effetto di artifici e raggiri posto in essere dall'altro contraente attraverso la condotta di Controparte_3 .

In via subordinata la CP_2 assumeva come doveva trovare applicazione l'art. 1440 c.c., e quindi la CP_1 , che consapevolmente aveva profittato degli artifici e raggiri, doveva essere tenuta al risarcimento dei danni provocati.

L'opponente chiedeva di revocarsi il decreto opposto e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della CP_1 alla restituzione delle maggiori somme ingiustamente percepite dalla detta società.

Si costituiva in giudizio l'opposta, riconoscendo l'errore nella quantificazione del corrispettivo, e chiedendo nel resto il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali dall'opponente e la condanna della medesima al pagamento della minor somma, rispetto a quella ingiunta, di euro 76.232,69.

Il primo giudice, assunta una prova orale, decideva la causa nei termini sopra indicati.

Il tribunale riteneva giuridicamente infondata la prospettazione dell'opponente, osservando, quanto alla domanda di annullamento del contratto, come la società opponente non potesse considerarsi vittima di alcun raggirò posto in essere dalla controparte atteso che, come affermato dalla medesima, e confermato dall'istruttoria, i costi delle varie spedizioni erano sempre stati concordati preventivamente tra l'opposta ed il CP_3 che rappresentava l'opponente in sede contrattuale, il cui consenso negoziale non poteva pertanto ritenersi in alcun modo dirsi carpito attraverso l'inganno.

Né, anche volendo ipotizzarsi una collusione del CP_3 con l'odierna opposta, poteva trovare applicazione il secondo comma dell'art. 1439 c.c., difettando in capo al CP_3 la qualità di terzo.

Il tribunale escludeva che le condizioni negoziali asseritamente più onerose relative alle varie spedizioni oggetto di giudizio potessero considerarsi riconducibili all'effettiva esistenza di un conflitto di interessi tra il CP_3 e la società opponente piuttosto che ad una libera contrattazione tra le parti ovvero, ancora, ad una migliore qualità del servizio reso dalla CP_1 rispetto ad altri operatori, non risultando inoltre l'esistenza di alcuna normativa di settore che imponga inderogabilmente il calcolo dei costi per la sosta delle merci secondo le modalità indicate dalla società opponente vietando che la determinazione dei medesimi possa invece essere lasciata alla volontà delle parti contraenti.

L'opposizione era formalmente accolta soltanto con riguardo ad un errore contabile commesso dalla

parte opposta nella determinazione della somma oggetto di ingiunzione, errore peraltro riconosciuto dalla stessa CP_1 in comparsa di risposta.

Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di tre motivi, da CP_2 che ne chiede la riforma, con il rigetto della domanda di pagamento proposta da Controparte_1 e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale.

Si è costituita in giudizio parte appellata, chiedendo il rigetto della impugnazione.

La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022.

Con il primo motivo l'appellante assume la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e di difesa, per avere il primo giudice disposto la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221 comma 4 DL 34\2020, dell'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in tal modo determinando il venir meno della discussione orale della causa.

Altra ragione di nullità doveva ravvisarsi nella violazione del principio di concentrazione commessa dal tribunale, che aveva provveduto al deposito telematico della sentenza senza neppure curare che della stessa venisse curata la comunicazione ad opera della cancelleria, che difatti non vi era stata.

Il motivo è infondato.

Osserva la Corte come dall'esame degli atti di causa, risulta che il tribunale:

con provvedimento del 13-8-2019, fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 16 aprile 2020;

con provvedimento del 9-4-2020 differiva, per i medesimi incombenti, al 7 ottobre 2020, l'udienza già fissata per il 16 aprile 2020;

con provvedimento del 9 agosto 2020, disponeva che detta udienza fosse trattata con le modalità previste dall'art. 221 c. 4 D.L. 34\2020, così come convertito dalla legge 77\2020;

sempre dall'esame del fascicolo di primo grado risulta che:

in data 2 ottobre 2020 la CP_2 depositava una memoria difensiva intitolata "trattazione scritta nell'interesse di CP_2 (di 43 pagine);

la sentenza veniva pubblicata in data 7 ottobre 2020.

Risulta in atti come la CP_2 né dopo la emissione del provvedimento che disponeva la trattazione scritta dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., né con la memoria difensiva depositata il 2 ottobre 2020, abbia eccepito la violazione del procedimento decisionale previsto dalla norma appena citata.

Ritiene la Corte come la CP_2 avrebbe dovuto far constare, con la prima difesa successiva alla decisione del tribunale di disporre la trattazione scritta dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. omettendo

in tal modo la discussione orale della causa, sostituita da note scritte, il proprio dissenso ed insistere per il rispetto delle modalità decisionali previste dalla citata disposizione.

In assenza di una manifestazione di questo dissenso, l'ipotizzato scostamento dal modello legale dell'art. 281 sexies c.p.c., non rileva, dovendo ritenersi che l'odierna appellante, ai sensi dell'art. 157 terzo comma c.p.c., abbia tacitamente rinunciato a dolersi della inosservanza della disposizione.

Parimenti priva di rilevanza è la questione relativa alle modalità di deposito della sentenza, che è stata portata a conoscenza delle parti con modalità tali da non pregiudicare alcuno dei diritti di difesa.

Con il secondo motivo, la CP_2 assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto infondata la domanda di annullamento del contratto di spedizione dedotto in causa, e comunque per avere ritenuto inesistente il dolo determinante del consenso ex art. 1439 c.c., o comunque quello incidente ex art. 1440 c.c.

Secondo l'appellante l'affermazione del tribunale, secondo cui i costi delle varie spedizioni sarebbero stati sempre concordati preventivamente tra l'opposta ed il sig. CP- che rappresentava la CP_2 e quindi il consenso negoziale di quest'ultima non poteva ritenersi carpito con l'inganno, era smentita da numerosi elementi di prova documentali e dalla istruttoria orale.

Assume l'appellante che dal quadro istruttorio era emerso come il sig. CP-, valendosi del ruolo dirigenziale assunto nella CP_2 avrebbe sistematicamente favorito la CP_1, incaricando esclusivamente la stessa di tutte le attività di spedizione nel corso degli anni dal 2010 al 2016, riconoscendo alla stessa compensi superiori a quelli di mercato e autorizzando rimborsi di costi non sostenuti, il tutto quantomeno con la certa conoscenza da parte dello spedizioniere, degli artifici e raggiri posti in essere dal proprio dirigente, che poi avevano determinato il suo licenziamento e l'instaurazione di un procedimento penale a suo carico.

Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia, da parte del tribunale, delle ulteriori domande dalla medesima proposte, ed in particolare quella risarcitoria ex art. 1440 c.c. ed ex art. 1337 c.c., quella di compensazione e quella di ripetizione ex art. 2033 c.c.

Il secondo ed il terzo motivo, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente.

Il tribunale, seppure con motivazione assai sintetica, ha escluso l'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1439 comma 1 e comma 2, dal momento che la CP_2 aveva agito, manifestando la propria volontà negoziale, attraverso il proprio rappresentante sig. CP-, il cui consenso non poteva certamente considerarsi viziato, posto che lo stesso era l'autore, e non il destinatario, degli asseriti raggiri.

Sempre la qualità di rappresentante della CP_2 rivestita dal CP-, escludeva la possibilità di assegnare

al medesimo la qualità di terzo, ai fini dell'ipotesi di annullabilità del contratto, prevista dal secondo comma del predetto art. 1439 c.c.

Questa ratio decidendi della decisione, non è stata confutata dalle critiche dell'appellante, che non spiega le ragioni per le quali la condotta tenuta dal proprio rappresentante dovrebbe essere assimilata a quella dell'altro contraente, o di un terzo, ai fini della domanda di annullamento disciplinata dall'art. 1439 c.c.

Non può peraltro non essere ricordato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui "con riguardo al contratto stipulato da una società di capitali a mezzo del proprio organo rappresentativo, l'annullabilità per dolo, ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., è ravvisabile in relazione ad artifici o raggiri posti in essere dall'altro contraente, o da un terzo, non anche, pertanto, in relazione a comportamenti di detto organo nell'ambito del rapporto interno con l'ente rappresentato" (Cass. 6278\1990).

La società, che assuma la qualità di parte di un contratto, esprime la sua volontà negoziale attraverso il proprio organo rappresentativo.

Un vizio del consenso, per effetto di artifici o raggiri, non è identificabile in relazione a comportamenti che si esauriscano nel rapporto fra rappresentante e rappresentato, non potendo lo stesso contraente essere autore e vittima dell'inganno.

Le stesse ragioni appena esposte giustificano l'infondatezza della domanda ex art. 1440 c.c., e di quella volta ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 1337 c.c., sulle quali il primo giudice non si è pronunciato espressamente.

La previsione di cui all'art. 1440 c.c. si differenzia dalla precedente solo per la minore intensità del dolo, non idoneo a determinare il vizio della volontà ma in grado di determinare le modalità del negozio, rendendolo più gravoso per una delle parti.

Escludendo, per quanto sopra osservato, la rilevanza della condotta del sig. ^{CP-} al fine di ritenere un vizio del consenso della società rappresentata, ne deriva che anche la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 1440 c.c. non ha fondamento.

Anche la domanda di restituzione dei costi per la sosta della merce, riconosciuti alla ^{CP_1} ma non dovuti, ha come presupposto, nella prospettazione attorea, l'invalidità dell'attività negoziale posta in essere dal sig. ^{CP-} per conto della ^{CP_2}

Ciò che l'odierna appellante lamenta è che il predetto proprio dirigente avesse nel corso degli anni riconosciuto alla ^{CP_1}, che curava il trasporto della merce prodotta da ^{CP_2} dalla sede di quest'ultima sino al porto di Genova, il rimborso di costi di sosta della merce in attesa di essere

imbarcata, con termini e modalità del tutto deteriori rispetto a quelli praticati dagli altri operatori del settore, quantificati in misura pari al numero di giorni complessivamente impiegati dal vettore terrestre, dalla data di carico sino a quella di effettiva partenza della nave, ma in realtà non effettivamente sopportati da **CP_1** .

Anche in questo caso, considerato come il pagamento delle spese di sosta è avvenuto in base ad accordi tra le due società, il venir meno della causa del pagamento, nella stessa prospettiva dell'appellante, non potrebbe che derivare dalla ritenuta invalidità dell'attività negoziale della **CP_2** per un vizio del consenso, ipotesi che, per quanto già esposto, deve escludersi.

Quanto, infine, alla domanda di compensazione avanzata, è evidente che questa presuppone l'accertamento di un credito della **CP_2** nei confronti della **CP_1** , la cui esistenza non è emersa in giudizio.

L'appello proposto risulta, per le ragioni che precedono, infondato, e la sentenza impugnata deve essere confermata.

Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza dell'appellante, sulla stessa devono gravare le spese processuali dell'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile (cause di valore da euro 260.001 ad euro 520.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, in euro 13.560,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228/2012.

P.Q.M.

a) respinge l'appello proposto da **Controparte_2** e conseguentemente conferma la decisione di primo grado;

b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di **Controparte_1** delle spese processuali di questo grado di appello, liquidate in euro 13.560,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;

c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022.

Il Presidente est. Carlo Maddaloni